

1501055-36.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... definitiva, sendo a primeira por crime de tráfico de drogas e a segunda por corrupção ativa, não sendo, portanto, primárias e portadoras de bons antecedentes. Incabível, enfim, a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Noutro giro, é o caso de absolver os imputados da prática do crime da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

A configuração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501055-36.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501055-36.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143258/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 18148638 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 902/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2143258 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA, LILIAN COSTA BATISTA e MANDERSON MATIAS BATISTA (fls. 144/146), qualificados nos autos, dando-os como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em período ainda não determinado, mas certo que até o dia 26 de maio de 2021, em horário e local incertos, nesta Cidade e Comarca de Embu das Artes, ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA, qualificada a fls. 14, LILIAN COSTA BATISTA, qualificada a fls. 15, e MANDERSON

MATIAS BATISTA, qualificado a fls. 16, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta também que, no dia 26 de maio de 2021, por volta da meia noite, na Rua dos Angelins, n.º 50, Embu Mirim, nesta Cidade e Comarca de Embu das Artes, ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA, qualificada a fls. 14, LILIAN COSTA BATISTA, qualificada a fls. 15, e MANDERSON MATIAS BATISTA, qualificado a fls. 16, traziam consigo e transportavam, com a finalidade de fornecer a consumo de terceiros, drogas consistentes em 1500 mililitros de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano/tricloroetileno), acondicionados em 171 porções; 870 gramas de maconha (tetrahydrocannabinol), acondicionadas em 275 porções; 1.300 gramas de cocaína, acondicionadas em 1.647 porções; e 382 gramas de crack, substância derivada da cocaína, acondicionadas em 1.634 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 51/52 e laudos de constatação de fls. 56/62."

A denúncia foi recebida em 14.06.2021 (fls. 148/149).

Regularmente notificados (fls. 196, 197 e 205), os acusados apresentaram defesas prévias, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 186/190 e 228/229).

Deferida a substituição a prisão preventiva por domiciliar, em favor da acusada ANNE (fls. 206/207).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 238/239).

Na data aprazada, colheram-se os depoimentos das testemunhas, e os réus foram interrogados (mídias acostadas aos autos - fls. 311).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 345/355), requerendo, preliminarmente, a vinda do laudo faltante (fls. 333 e 336). No mérito, pugnou pela procedência da demanda, condenando-se os acusados nos termos da denúncia, pois devidamente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, estando as negativas dos réus isoladas das demais provas produzidas no feito, em especial pelos depoimentos das testemunhas. Quanto à pena, na primeira fase, em relação a todos os acusados e no que toca ao delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, requereu a fixação acima do mínimo legal, em virtude de os inculcados trazerem consigo e transportarem cocaína e crack. Ainda nesta fase, apontou os maus antecedentes das rés Lilian e Anne. Por fim, pleiteou o regime inicial fechado, sem substituição das penas corporais por restritivas de direito ou concessão de qualquer benefício.

A Defesa das rés Anne e Lilian apresentou alegações finais (fls. 367/375), requerendo a improcedência da demanda e a absolvição das acusadas, por não existir contra elas qualquer prova que demonstre de forma clara e inequívoca a efetiva participação no crime em apreço, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo apelo em liberdade, visto que possuem residência e domicílio fixo e filhos menores de 12 (doze) anos.

A Defesa do réu ManderSON ofertou alegações finais (fls. 376/381), requerendo a absolvição do acusado, tendo em vista a fragilidade das provas carreadas aos autos, havendo dúvidas quanto ao envolvimento direto e principal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Pugnou também pela benesse do art. 41 da Lei 11.343/2006, face à recuperação total do produto do crime e, ainda, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como todas as atenuantes que tem por direito, em seu patamar máximo de redução, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), no boletim de ocorrência (fls. 47/50) e nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 51/52, 56/59 e 60/62) e

nos laudos definitivos (fls. 394/396 e 402/404). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos em poder dos acusados 1500 mililitros de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano/tricloroetileno), acondicionados em 171 porções; 870 gramas de maconha (tetrahidrocannabinol), acondicionadas em 275 porções; 1.300 gramas de cocaína, acondicionadas em 1.647 porções; e 382 gramas de crack, substância derivada da cocaína, acondicionadas em 1.634 porções. Os exames químico-toxicológicos atestaram que as substâncias entorpecentes apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, o policial militar Caio Cesar Campos (fls. 04/05) esclareceu que estavam em patrulhamento ostensivo de rotina, quando avistaram as réas Anne e Lilian paradas com mochilas. Tratando-se de local ermo e de ponto de tráfico, as abordaram e as questionaram do motivo de estarem no local e, percebendo que as duas não sabiam o que faziam ali, as indagaram o que havia nas mochilas, quando elas falaram que eram "aviões do partido", que estavam levando drogas e que aguardavam um rapaz, vulgo "MG". Disse que, na busca pessoal, na mochila de Lilian havia 508

"eppendorfs" contendo substância branca que se assemelha a cocaína, 1.300 pedras de substância que se assemelha a crack e 50 frascos de líquido que se assemelha a lança perfume e na mochila da Anne 90 porções de substância esverdeada que se assemelha a maconha, 747 "eppendorfs" contendo substância branca que se assemelha a cocaína, 220 pedras de substância que se assemelha a crack e 50 frascos de líquido que se assemelha a lança perfume. Narrou que, no momento em que as buscas pessoais ocorriam, Manderson apontou no começo da rua e ao ver a viatura correu, e jogou uma mochila no meio da rua. Ao ser abordado, Manderson disse que correu por que tinha drogas na mochila, sendo nela encontrado 185 porções de substância esverdeada que se assemelha a maconha, 320 "eppendorfs" contendo substância branca que se assemelha a cocaína, 114 pedras de substância que se assemelha a crack e 71 frascos de líquido que se assemelha a lança perfume. Por fim, falou que, após a chegada de Manderson, ninguém disse mais nada.

Em juízo, inquirido como testemunha, Caio reproduziu, essencialmente, a narrativa extrajudicial, atestando a veracidade dos fatos imputados na denúncia. Acrescentou que as acusadas apontaram que entregariam as drogas para "MG" e que, na abordagem, o próprio Manderson se identificou como "MG". Afirmou que nunca tinha visto os réus. Respondeu que Manderson também confessou a traficância e, ainda, que as acusadas abasteciam a "biqueira", do qual ele era responsável. Indagado, disse que uma das réas informou que seria responsável por retirar as drogas em certo local e entregar no endereço informado, mas que não sabia de onde vinham. Confirmou que, na hora da abordagem, estavam em três policiais. Não soube precisar distância do réu Manderson das acusadas, porém foi possível visualizá-lo tentando fugir ao notar a presença da viatura. Afirmou que o local é uma via comum, conhecida ponto de tráfico. Não se recordou dos trajés que os réus usavam e as cores das mochilas que carregavam.

A testemunha Anderson Pires Silva, em juízo, disse que, por volta da meia noite, patrulhavam pelo bairro, situado no local dos fatos, onde a venda de drogas é constante, quando avistaram duas mulheres com mochilas de grande porte nas costas e, considerando o horário e atitude delas, pararam a viatura e começaram a conversar com elas. Indagadas sobre o que havia nas mochilas, de imediato, ambas responderam que na mochila havia drogas. Pedirão, então, para que abrissem as mochilas, sendo nelas localizadas muitas drogas. O que puderam verificar, pois pediram para que elas abrissem as mochilas. Narrou que as acusadas disseram que estavam esperando um rapaz, de alcunha "MG", para entregarem as drogas, pois este seria o responsável pelo recebimento e distribuição dos entorpecentes nos pontos de vendas. Falou que, enquanto aguardavam a policial feminina para busca pessoal nas duas mulheres, visualizaram um rapaz, no caso, Manderson, que também estava com uma mochila e que tentou correr, dispensando a mochila no chão, mas foram ao seu encalço e, na sequência, interceptaram-no, abordando-o. Afirmou que na mochila dele

também continha bastante droga e que o réu confessou que a droga seria para venda e que ele era o responsável pelo tráfico no local, gerente de diversas "biqueiras". Confirmou que o réu confessou ser o responsável pelas drogas e que seu vulgo é "MG". Indagado se o acusado conhecia as rés, se eles tinham ligação, respondeu que a ligação seria só referente ao crime, pois disseram que o "crime" contratava as pessoas para quem ele iria entregar a droga, que entrariam em contato com ele, através de ligação, para se encontrarem para fazer a distribuição das drogas. Disse que acredita que a ligação entre o acusado e as rés era direta através de celular. Não soube precisar a distância que Manderson estava das rés, mas que puderam visualizar sua ação com precisão, pois se tratava de local iluminado. Não soube precisar o horário da abordagem, mas afirmou que ela se deu, provavelmente, entre meia noite e uma da manhã. Falou que não verificaram os celulares das rés, que nenhum dos policiais teve acesso aos aparelhos. .

O réu Manderson ficou em silêncio em solo policial (fl. 10). Em juízo, negou os fatos imputados. Disse que não conhecia as rés e que nunca as viu. Afirmou que os policiais o abordaram, perguntando sobre drogas, tendo ele respondido que não sabia de nada. Então, foi colocado em uma viatura. Após, deram uma volta com ele, soltando-o, na sequência. Depois, os abordaram novamente, ocasião que as três mochilas de drogas já estavam com eles, na viatura. Disse que foi colocado novamente na viatura, com as três mochilas, e que, na sequência, abordaram as demais rés e as colocaram na viatura. Negou que estivesse com a droga. Afirmou que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão. Falou que passava pelo local porque estava indo para casa, pois mora na rua dos fatos. Falou que foi abordado a primeira vez, no portão de sua casa, por volta das sete horas da noite, e depois liberado. Na segunda vez, estava voltando para casa, na mesma rua, porém em outro ponto. Depois, os policiais pegaram as acusadas, em outra rua, num ponto de ônibus. Disse que, quando as rés foram abordadas, não tinha nada com elas. Contou que os policiais mexeram em seu telefone celular, devolvendo-o depois.

A ré Lilian ficou em silêncio em solo policial (fl. 09). Em juízo, disse que "Neguinho", que não conhece bem, a chamou, dizendo que tinha um "trampo" para ela fazer, porém não lhe disse o que seria. Falou que para o trabalho seria necessário que ela levasse mais uma amiga. Afirmou que perguntou a "Neguinho" se se tratava de droga, tendo ele respondido que não. Então, chamou Anne Caroline para lhe ajudar, pois a conhecia há tempos. Afirmou que Anne foi na frente, antes, sendo que solicitou um uber para que ela também se dirigisse ao local depois. Afirmou que foram separadas para o local e que não chegaram juntas. Alegou que não conhecia Manderson, mas que "Neguinho" falou que Manderson estaria no local para recebê-las. Negou saber que entregaria drogas, porém sabia que "Neguinho era meio doidão". Falou que foram até o local sem nada, sem as mochilas, e que "Neguinho" falou que no local iriam encontrar uma pessoa chamada Manderson, ocasião que receberia orientações sobre o trabalho. Não soube dizer onde as drogas foram encontradas. Falou que, quando chegou no local, Anne e Manderson já havia sido presos e os policiais já estavam com um monte de bolsas. Disse que já foi processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Alegou que não conhecia os policiais. Disse que tudo, inclusive o valor do serviço, seria combinado pessoalmente. Não soube informar o porquê do horário avançado da noite para realização do trabalho.

A acusada Anne ficou em silêncio em solo policial (fl. 08). Em juízo, disse que Lilian ligou pra ela, chamando-a para fazer um trabalho, porém não falou qual seria o trabalho. Falou que com tem quatro filhos e estava desempregada, acabou aceitando, sendo que Lilian lhe passou o número de telefone de Manderson. Então, contatou Manderson, que lhe disse que para ir até ele, passando-lhe o endereço, afirmando que ao chegar no local saberia qual seria o trabalho. Afirmou que foi até o Centro de Embu de ônibus e lá, Manderson, falou para ela pegar um Uber até o local por ele informado. Falou que desceu do Uber e, aproximadamente, cinco minutos depois, foi abordada por quatro policiais, os quais já foram dizendo seu nome e afirmando que estavam lhe esperando. Contou que os policiais pegaram o seu celular e uma bolsinha com pertences e dinheiro que portava e falaram que a levariam até o Manderson. Disse que os policiais se dividiram em duas duplas, uma delas ficou

conversando consigo e a outra dupla saiu na viatura. Falou que os dois policiais passaram a indagar se conhecia o acusado Manderson, afirmando ela que não o conhecia, mas que estava indo ao seu encontro. Contou que foi levada até o local que Manderson já havia sido abordado, fora de uma casa, e dois policiais já estavam com ele. Na sequência, Manderson e os policiais ingressaram na residência, enquanto ela permaneceu do lado de fora ao lado de um policial. Alegou que os policiais a todo momento mexiam no celular dela e que, a acusada Lilian enviou uma mensagem, sendo que o próprio policial militar respondeu, passando-se por ela. Afirmou que ficou sentada na escada da casa, com um policial a acompanhando, e que Manderson estava dentro da casa com o outro policial. Cerca de 40 minutos depois, Lilian chegou e dois policiais foram busca-la e a trouxeram até a escada, onde elas ficaram sentadas, sem poder se comunicar. Falou que os policiais saíram da casa com Manderson, trazendo uma ou duas mochilas, sendo que já havia uma mochila na viatura. Depois, ela e os demais réus foram avisados que seriam encaminhados para a Delegacia para averiguação. Não soube dizer se as mochilas foram encontradas na residência, pois os policiais já tinham abordado o Manderson. Respondeu que a pessoa que ofereceu o trabalho era um conhecido da Lilian, mas que ela não o conhece. Esclareceu que ia encontrar com Lilian no Centro de Embu, mas esta não conseguiu chegar. Então, Lilian lhe passou o endereço e ela foi na frente. Falou que, na ocasião, os filhos ficaram em casa com sua mãe. Disse que já foi processada por corrupção ativa e atualmente responde por processo que não sabe do que se trata, mas que ficou presa por ele. Não soube dizer se a casa que os policiais ingressaram pertencia ao Manderson, sendo que residência ficava cerca de quinze casas para frente de onde Manderson tinha dado o endereço. Falou que conhece Lilian há quatro anos, pois ela mora perto de sua tia. Confirmou que ambas as solicitações do aplicativo Uber foram feitas do seu celular e que não chegou no local com nenhuma mochila, só com sua bolsa de mão. Afirmou que não houve abordagem de policial feminina no local, que os policiais as revistaram.

Como se vê, em que pesem as negativas dos acusados, os seguros, claros e congruentes testemunhos dos policiais militares, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar os réus (como na espécie, até porque não os conheciam) -, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva.

Embora a defesa das rés alegue que os policiais manusearam os celulares dos acusados Manderson e Anne para atraí-los até o local, em oportunidades diferentes, tal fato não se confirmou pelas provas colhidas nos autos, não havendo sequer apreensão de referidos celulares. Ademais, a tese de que as mochilas já estavam em poder dos policiais não é minimamente crível, pois foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes de natureza diversificada - sendo que um flagrante por tráfico poderia ser "fabricado" com uma quantidade consideravelmente inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos -, e a origem lícita e as razões para o armazenamento das drogas em poder dos imputados não foram comprovadas nos autos. As defesas não comprovaram o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva alegado (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhes incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev.,

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Assentadas a materialidade e a autoria delitivas, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos. Consoante acima exposto, restou configurado, estreme de dúvidas, o tipo misto alternativo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas com os acusados, descortino a gravidade em concreto da conduta, a indicar o grau de envolvimento dos agentes na atividade criminosa, e não um desvio pontual, máxime porque ao pequeno traficante não é confiada expressiva carga de drogas.

Como destacou o eminente Desembargador Camargo Aranha Filho na Apelação Criminal nº 1523060-25.2020.8.26.0228, julgada pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 07.06.2020, em acórdão de sua relatoria, "na interpretação da referida causa de diminuição de pena deve o juiz atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o objetivo legal foi de beneficiar com a sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento. (...) a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas pode vir assentada na prova indiciária, que se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), sob pena de inviabilizar a repressão penal a este tipo de delito, na medida em que os criminosos não circulem com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas' (STF, HC nº 101.519, Relator Ministro Luiz Fux, DJe em 25/4/2012). Acresço que a primariedade e os bons antecedentes não determinam de forma sistemática a incidência da causa de diminuição."

Em suma: a situação dos acusados, surpreendidos na posse de quantidade portentosa de drogas, não é própria de quem está se iniciando neste hediondo comércio, de modo que não está preenchido o requisito de não dedicação a atividades criminosas.

Ainda, consta de fls. 168 e 170 que as acusadas Lilian e Anne foram condenadas criminalmente em momento anterior, em sede definitiva, sendo a primeira por crime de tráfico de drogas e a segunda por corrupção ativa, não sendo, portanto, primárias e portadoras de bons antecedentes.

Incabível, enfim, a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Noutro giro, é o caso de absolver os imputados da prática do crime da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

A configuração dessa modalidade especial de associação criminosa exige que ao menos duas pessoas se agrupem de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 34 (tráfico de maquinário) da Lei nº 11.343/2006. É a constatação desse vínculo subjetivo duradouro que se presta a distinguir o mero concurso eventual e episódico de pessoas do crime autônomo do art. 35 da Lei de Drogas. Daí pontificarem ALICE BIANCHINI, LUIZ FLÁVIO GOMES, ROGÉRIO SANCHES CUNHA e WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA que "a consumação, que se dá com a formação da *societas criminis*, protraí-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente). Como já alertado acima, não há necessidade de que algum dos delitos venha a ocorrer, desde que demonstrado

que a associação de pessoas continha um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade." (Legislação criminal especial – 2. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – Coleção ciências criminais, vol. 6 – coordenação Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha, p. 265).

O Ministério Público não demonstrou o vínculo associativo estável, duradouro e permanente entre os acusados, tampouco assinalou com qualquer relato de investigação anterior sólida e específica tendente a apurar a caracterização da *societas sceleris* entre eles, elucidando a ocorrência do delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Como destacou o eminente Desembargador Guilherme de Souza Nucci na Revisão Criminal nº 0005607-96.2020.8.26.0000, julgada pelo 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.12.2020, em acórdão de sua relatoria, "a vinculação traficância e associação não é automática, requerendo, para tanto, provas no sentido de demonstrar a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus membros, o papel por cada um desempenhado, não obstante a desnecessidade de haver habitualidade, ou seja, não se exige o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos artigos 33 e 34, da Lei em comento. A associação não deve ser extraída de um fato isolado, requerendo, para sua comprovação, investigação mais apurada. (...). O Estado precisa efetivamente investigar os fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma associação."

Nesse quadro de insuficiência probatória, impõe-se a absolvição dos acusados pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por força do princípio do *in dubio pro reo*.

Aperfeiçoou-se, assim, a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

MANDERSON MATIAS BATISTA

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Consoante supra consignado, a quantidade e a variedade portentosa de drogas, de reconhecido potencial lesivo, enseja, em linha de princípio, maior reprovação penal. Todavia, a fim de não incorrer em *bis in idem*, valorá-la-ei apenas na terceira etapa da dosimetria para afastar o redutor estatuído no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos HCs n. 109.193/MG e 112.776/MS, firmou a orientação de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da pena, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de *bis in idem*.

2. Uma vez que o Juiz sentenciante utilizou o mesmo fundamento (quantidade de drogas apreendidas) para justificar tanto a exasperação da pena-base quanto a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, deve ser determinado o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja procedida à nova dosimetria da pena, dessa vez com a utilização da quantidade de drogas apreendidas em somente uma das etapas da dosimetria.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 358850/SP n. 2016/0151207-0, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 26.09.2018);

[...] Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas.

3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao *bis in idem*. Precedentes.

4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena.

5. Reafirmação de jurisprudência. (STF, ARE 666334 RG, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014, DJe 05.05.2014); e APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÃO. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do 70, do Código Penal, todos enlaçados em concurso material de delitos. Preliminar de nulidade. Ilícitude da prova. Não reconhecimento. Busca e apreensão domiciliar desprovida de mandado judicial. Ingresso dos policiais autorizado pelo réu. Procedimento legítimo diante da prática de crime permanente. Advertência sobre o direito ao silêncio. Desnecessidade. Mérito. Materialidade e autoria dos delitos não questionadas, mesmo porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Condenação acertada. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade de substâncias apreendidas para elevar a pena-base e impedir a aplicação do tráfico privilegiado, configura vedado bis in idem. Basilar devolvida ao piso legal. Afastada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido em ocasião de calamidade pública. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Precedentes. Caso concreto que não admite a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Quantidade elevada de drogas que revela a dedicação do sentenciado à atividade criminosa. Bem reconhecido o concurso formal entre os artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03. Orientação mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e acolhida nesta Colenda Câmara. Tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos. Regimes iniciais mantidos. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 1502451-43.2020.8.26.0544, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 31.05.2021). (Negritei).

De outra banda, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; o réu é primário; o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, remanescendo a pena inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena – conforme motivado acima –, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal. Embora o réu seja primário, foi apreendida em seu poder grande quantidade e variedade de drogas, de alto poder viciante, e as circunstâncias que cercaram a ação delituosa denotam que ele faz da traficância seu hábito de vida, elementos que patenteiam a maior reprovabilidade e a gravidade concreta da conduta, de maneira que reputo ser o regime mais severo o único suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, consistente em inibir a prática de novas empreitadas delitivas (nesse particular: TJSP, Apelação Criminal nº 1505924-49.2019.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 20.05.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1502451-43.2020.8.26.0544, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 31.05.2021).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena imposta (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do CP).



LILIAN COSTA BATISTA

Na primeira fase, a quantidade e a variedade exorbitantes de drogas ensejam maior reprovação penal, pois apreendidos 1500 mililitros de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano/tricloroetileno), acondicionados em 171 porções; 870 gramas de maconha (tetrahidrocannabinol), acondicionadas em 275 porções; 1.300 gramas de cocaína, acondicionadas em 1.647 porções; e 382 gramas de crack, substância derivada da cocaína, acondicionadas em 1.634 porções.

Não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social da acusada.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; a ré ostenta uma condenação criminal anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (fls. 168), que configura reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, I, todos do CP), a qual valorarei na fase subsequente da aplicação da pena, premunindo o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

Assim, exaspero a pena-base em 1/8, mercê da quantidade e variedade de drogas, fixando-a em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP) em crime de tráfico de drogas – conforme acima se adiantou –, não incidindo atenuantes, razão pela qual agravo a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária anteriormente fixada definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica da ré (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, tendo em vista a variada e expressiva quantidade de drogas apreendidas e a reincidência da ré (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tanto em razão da quantidade de pena imposta, quanto mercê da reincidência específica (arts. 44, incisos I e II, e 77, caput e inciso I, ambos do CP).

ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA

Na primeira fase, a quantidade e a variedade são exorbitantes de drogas e ensejam maior reprovação penal, pois apreendidos 1500 mililitros de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano/tricloroetileno), acondicionados em 171 porções; 870 gramas de maconha (tetrahidrocannabinol), acondicionadas em 275 porções; 1.300 gramas de cocaína, acondicionadas em 1.647 porções; e 382 gramas de crack, substância derivada da cocaína, acondicionadas em 1.634 porções.

Não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social da acusada.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; a ré ostenta uma condenação criminal anterior transitada em julgado por corrupção ativa, datada de mais de 5 anos, que não configura reincidência, mas encarna mau antecedente (fls. 170); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

Assim, exaspero a pena-base em 1/5, mercê da quantidade e variedade das drogas e do mau antecedente, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes, remanescendo a pena tal qual dosada na primeira fase.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária anteriormente fixada definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação

econômica da ré (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, "a" e "b", e § 3º, do Código Penal, em vista da variada e expressiva quantidade de drogas apreendidas e dos maus antecedentes.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena imposta (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do CP).

Ressalto que o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento das penas corporais ora fixadas para o semiaberto (art. 387, § 2º, do CPP).

In casus, o tempo de prisão provisória - os réus estão presos desde 26.05.2021 - não autoriza a alteração do regime penitenciário, ex vi do disposto no art. 112, V e VII, da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

A detração, instituto inerente à prolação da sentença condenatória para fins de estabelecimento de regime inicial, não deve ser confundida com o cômputo do tempo de segregação preventiva na progressão de regime, que compete ao juízo da execução. Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018).

Denego, por fim, o direito ao apelo em liberdade.

Da gravidade concreta do crime emerge que, caso soltos, os acusados poderão colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terão os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir.

(...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para:

1) ABSOLVER o réu MANDERSON MATIAS BATISTA, já qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP; e CONDENÁ-LO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

2) ABSOLVER a ré LILIAN COSTA BATISTA, já qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP; e CONDENÁ-LA, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

3) ABSOLVER a ré ANNE CAROLINE SANTOS BARBOSA, já qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP; e CONDENÁ-LA, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Os acusados responderam ao processo presos, e, permanecendo os motivos justificadores da segregação cautelar, continuarão custodiados (art. 387, § 1º, c.c. art. 312, ambos do CPP). Recomendem-se os acusados Manderson e Lilian às prisões em que se encontram. Quanto à ré Anne Caroline, mantenho a prisão domiciliar, nos termos da decisão de fls. 206/207.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso).

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhes concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União – consoante fundamentação supra -, o que faço com fulcro no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor da patrona nomeada para o acusado Manderson, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Certificado o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; (d) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Cumpridas as demais atribuições cartorárias de praxe, arquivem-se os autos definitivamente, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA